

1500526-33.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/06).

Com relação ao crime de tráfico de drogas, as provas apontam, indene de dúvidas, que o acusado trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico. Com efeito, os policiais, em depoimentos coesos e livres de contradição, prestados tanto na fase policial como em Juízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500526-33.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500526-33.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2333125/2021 - DEL.POL.ARIRANHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Felipe Ferreira Pimenta

Vistos.

JOÃO GUILHERME DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que anteriormente ao dia 07 de dezembro de 2021, em data e local desconhecidos, o denunciado associou-se com o adolescente Luis Paulo Rosa Quirino, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 14h15min, na Rua Siqueira Campos, altura do numeral 587, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, o denunciado, juntamente com o adolescente Luis Paulo Rosa Quirino, para fins de tráfico: a) vendeu 02 (dois) microtubos do tipo eppendorf, contendo em seu interior a droga cocaína, com massa líquida de 0,15g; b) trazia consigo 02 (dois) microtubos do tipo eppendorf, contendo em seu interior a droga cocaína, com massa líquida de 0,2g, e 06 (seis) porções da droga tetrahydrocannabinol, com massa líquida de 14g; c) guardava 38 (trinta e oito) microtubos do tipo eppendorf,

contendo em seu interior a droga cocaína, com massa líquida de 3,8g, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Inicialmente, anoto que a prisão em flagrante do acusado foi homologada e convertida em prisão preventiva (fl. 90/93).

No mais, o réu foi notificado (fl. 130/131) e apresentou, por meio de sua Causídica, defesa preliminar (fls. 136/138).

Aos 18 de março de 2022 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi indeferido pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa (fl. 145).

Em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi revisada e mantida a custódia cautelar do acusado (fl. 197).

Seguindo, em audiência de instrução realizada aos 14 de junho de 2022, colheu-se o depoimento das testemunhas Silvia Aparecida Gonçalves Leite Betoschi, Luis Paulo Rosa Quirino (menor), Silvio Riva e José Renato Gagliardi e, por fim, foi interrogado o réu. Encerrada a instrução sem requerimento das partes por outras diligências, as partes ofertaram memoriais finais orais (fls. 215).

O Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência da pretensão acusatória inicial, postulando a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, mas apenas pelos núcleos do tipo "trazer consigo" e "guardar"; no mais, opinou pela absolvição do réu quanto ao delito de associação para o tráfico por falta de provas. Em sede de dosimetria da pena, pediu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando-se a diversidade de drogas e as circunstâncias pessoais do réu, pois embora não registre condenação definitiva, foi condenado em primeira instância por crime de tráfico de drogas, o que sugere conduta social negativa e, por fim, sugeriu a aplicação de regime inicial semiaberto e destacou a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas e, no mais, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/11), boletim de ocorrência (fls. 12/19), auto de exibição e apreensão (fls. 22/25), laudo de constatação (fls. 28/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/112), que atestou ser cocaína na forma de crack, cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) as substâncias apreendidas. Acrescente-se os depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

A autoria, da mesma forma, é incontroversa.

A testemunha Silvio Riva, na fase policial, prestou o seguinte depoimento: "que, nesta data, juntamente com policiais civis da Delegacia de Polícia Pindorama/SP deflagram operação para repressão do crime de um crime de roubo ocorrido naquela cidade tendo como investigados desse crime o indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e o adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO, sendo dois dos autores daquele crime, inclusive, contra aquele havia um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum de Catanduva/SP, exarado nos autos do Processo nº: 1505968-94.2021.8.26.0132. De posse de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até as imediações da residência de João Guilherme dos Santos situada Rua Siqueira Campos, nº 587, nesta cidade e observaram uma movimentação de pessoas típica com as de compra e venda de drogas; e por isso, resolveram realizar uma breve campanha naquele local. Incontinentemente, o depoente ficou em uma viatura mais distante do local, enquanto seu colega José Renato Gagliardi observava as negociações de compra e venda de drogas realizada pelo indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e o adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO e viu que este recebeu e entregou algo a uma mulher e passou as características dessa para o depoente. Após a saída dessa mulher daquele local, o depoente imediatamente conseguiu encontrá-la e questionou Silvia Aparecida Gonçalves Leite Betoschi acerca da aquisição da droga e esta lhe entregou 02(duas) porções da droga "crack" que acabara de comprar do indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e do adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO, inclusive, reconheceu este último nesta repartição. Nesse ínterim, o depoente soube que seu colega José Renato logrou êxito em abordar o

adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO e, em revista pessoal, localizou e apreendeu uma porção da droga "maconha" e a quantia de R\$ 30,00 fruto da venda que realizara. Em seguida, dirigiram-se até à casa do indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS onde estava Érika Fernanda Betochi, genitora deste, a qual os policiais civis leram e exibiram o teor do mandado de busca e apreensão. Antes do início das buscas, informou o depoente que lá chegou o indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e, durante a busca pessoal neste, encontraram, no bolso de sua bermuda: 02(duas) porções da droga "cocaína"; 06(seis) porções da droga "maconha" embaladas para a venda; a quantia de R\$ 10,00(dez reais) e um aparelho da marca Samsung. Ainda na residência do indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS o depoente encontrou escondidas no telhado da residência: 38(trinta e oito) "ependorf's", contendo a droga "crack=cocaína". Em seguida, indagaram o indiciado João Guilherme dos Santos acerca das drogas e ele confessou que as drogas lhe pertenciam, mas se destinava ao seu consumo. Diante dos fatos, deu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico ao indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e apreensão ao adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO conduzindo-os até esta Delegacia de Polícia." (fl. 05/06)

Em juízo, a testemunha Silvio relatou que se dirigiram até a residência do acusado João Guilherme para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo de Catanduva, por conta de investigação de crime de roubo, e chegando próximo ao imóvel, observaram movimentação típica de tráfico, asseverando que já existiam denúncias de que naquele ponto funcionava uma "biqueira". Os policiais que estavam mais à frente realizaram breve campanha e presenciaram o adolescente Luis Paulo vender drogas a uma mulher. Com base nas características informadas, o depoente procedeu à abordagem da citada mulher, enquanto os demais policiais iniciaram a busca na casa de João Guilherme. Ressaltou que João Guilherme chegou no imóvel e, abordado, foi com ele encontrada parte da droga e certa quantia em dinheiro e um celular; o acusado João Guilherme indicou onde estava o restante do entorpecente, escondido no telhado. Não presenciou a venda de drogas à testemunha Silvia, apenas a abordou e encontrou com ela o entorpecente adquirido. Silvia informou ter adquirido a droga de Luis Paulo e que ele estava sozinho, não recordando se ela mencionou alguma outra coisa sobre o acusado João Guilherme. Esclareceu que o mandado de busca e apreensão tinha como alvo a casa de João Guilherme.

A testemunha José Renato Gagliardi, na fase extrajudicial, prestou o seguinte depoimento: "que, nesta data, veio até esta cidade onde juntamente com policiais civis da Delegacia de Polícia Ariranha/SP deflagram operação para repressão do crime de um crime de roubo ocorrido na cidade de Pindorama/SP onde trabalha, tendo como investigados desse crime o indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e o adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO, sendo estes dois dos autores daquele crime, inclusive, contra o primeiro havia um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum de Catanduva/SP, exarado nos autos do Processo nº: 1505968-94.2021.8.26.0132. De posse de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até as imediações da residência de João Guilherme dos Santos situada Rua Siqueira Campos, nº 587, nesta cidade; e observaram uma movimentação de pessoas típica com as de compra e venda de drogas; e, por isso, resolveram realizar uma breve campanha naquele local. Incontinentemente, o depoente ficou em uma viatura observando as negociações de compra e venda de drogas realizada pelo indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e o adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO e viu que este recebeu e entregou algo a uma mulher e passou as características desta para seu colega Silvio que estava em outra viatura mais distante. Após a saída dessa mulher daquele local, soube que o Investigador Silvio conseguiu encontrá-la e questionou Silvia Aparecida Gonçalves Leite Betoschi acerca da aquisição da droga e esta entregou ao policial 02(duas) porções da droga "crack" que acabara de comprar do indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e do adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO, inclusive, reconheceu este último nesta repartição. Nesse ínterim, o depoente logrou êxito em abordar o adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO e, em revista pessoal, localizou e apreendeu uma porção da droga "maconha" e a quantia de R\$ 30,00 fruto da venda que realizara. Em seguida, dirigiram-se até à casa do

indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS onde estava Érika Fernanda Betoichi, genitora deste, a qual os policiais civis leram e exibiram o teor do mandado de busca e apreensão. Antes do início das buscas, informou o depoente que lá chegou o indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e, durante as busca pessoal neste, encontraram, no bolso de sua bermuda: 02(duas) porções da droga "cocaína"; 06(seis) porções da droga "maconha" embaladas para a venda; a quantia de R\$ 10,00(dez reais) e um aparelho da marca Samsung. Ainda na residência do indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS o depoente encontrou escondidas no telhado da residência: 38(trinta e oito) "ependorf's", contendo a droga "crack=cocaína". Em seguida, indagaram o indiciado João Guilherme dos Santos acerca das drogas e ele confessou que as drogas lhe pertenciam, mas se destinava ao seu consumo; já o adolescente negou os fatos. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico ao indiciado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS e apreensão ao adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO conduzindo-os até esta Delegacia de Polícia." (fl. 07/08).

Em juízo, a testemunha José Renato contou que o acusado João Guilherme e o adolescente Luis Paulo são suspeitos da prática de crime de roubo na cidade de Pindorama. Em contato com os policiais de Ariranha, estes informaram que no local funcionava um ponto de venda de drogas. Fizeram uma breve campana e presenciaram uma mulher adquirir drogas do adolescente Luis Paulo. Comunicaram o policial Silvio, que procedeu à abordagem da citada mulher, enquanto que os demais ingressaram na residência de João Guilherme, munidos do mandado de busca domiciliar. Ressaltou que o acusado João Guilherme chegou no imóvel após os policiais e, em revista pessoal, encontraram com ele duas porções de cocaína, seis porções de maconha, R\$10,00 em dinheiro e um aparelho celular. Disse que o réu indicou que o restante da droga - 38 ependorfs de cocaína - estava no telhado. Respondeu que foi Luis Paulo quem vendeu drogas a Silvia e que ele estava sozinho nesse momento; que o local em que ocorreu a venda ficava próximo à casa de João Guilherme, virando a esquina, a uns dez metros. Não viu João Guilherme em ato de venda de drogas. O acusado alegou que a droga apreendida em seu poder destinava ao seu consumo pessoal.

A testemunha Silvia Aparecida Gonçalves Leite Betoschi, em sede policial, declarou: "que é usuária de drogas e na data de hoje (07/12), foi até Luis na rua Siqueira Campos para comprar pedra. Neste ato fica sabendo se tratar do adolescente LUIS PAULO ROSA QUIRINO. Que adquiriu duas "pedras" por R\$ 10,00 cada. Que conhece Luis pela venda de drogas; que Luis vende a droga com um outro rapaz, conhecido pela declarante como João Guilherme, em uma esquina da Rua Siqueira Campos. Que anos atrás já comprava droga com Luis Paulo, mas parou de ir até a "biqueira" dele. Que foi abordada pelo policiais civis e em seu bolso do short estava as duas pedras que havia acabado de adquirir com Luis, que entregou-as aos policiais e foi conduzida até esta Delegacia." (fl. 09)

Em juízo, a testemunha Silvia disse que não conhece o acusado João Guilherme e nunca comprou drogas dele. Confirmou que quando foi abordada pelos policiais tinha consigo dois pinos de "pedra", que havia adquirido do adolescente Luis Paulo. Afirmou que no momento da compra, Luis Paulo estava sozinho. Ressaltou, ainda, que foi a primeira vez que adquiriu drogas do menor Luis Paulo. Negou ter dito na fase policial que já havia comprado entorpecente de Luis Paulo em ocasiões anteriores, bem como que ele praticava o comércio ilícito de drogas na companhia do acusado João Guilherme.

O adolescente Luis Paulo Rosa Quirino, que na fase extrajudicial fez uso do direito de permanecer em silêncio (fl. 10), em juízo negou a venda de drogas a Silvia. Conhece o acusado João Guilherme, que sabe ser usuário de drogas. Estava sozinho quando foi abordado por policiais e desconhece o motivo da abordagem. Responde a outro procedimento por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. O réu João Guilherme dos Santos declarou à autoridade policial: "que não possui advogado constituído, indiciou sua mãe Érika Fernanda Betoichi para ser avisada sobre sua prisão, destacando-se que estava presente nesta Delegacia de Polícia e foi informada sobre isso, disse não ter filhos e que não foi agredido pelos policiais. Sobre o fato, confessa que, nesta data, estava em sua casa quando

policiais civis adentraram na residência e, durante o varejamento, encontraram, no bolso de sua bermuda: 02(duas) porções da droga "cocaína"; 06(seis) porções da droga "maconha" embaladas para a venda; a quantia de R\$ 10,00(dez reais); um aparelho da marca Samsung. Ainda o interrogado indicou aos policiais civis onde estavam escondidas no telhado de sua residência: 38(trinta e oito) "eppendorfs", contendo a droga "crack=cocaína". Confessa o interrogado que essas drogas lhe pertencem e se destinam ao seu consumo pessoal, mencionando que é usuário de drogas. Acerca da do adolescente LUÍS PAULO ROSA QUIRINO, o interrogado apenas o conhece e não se associou a este para cometer o crime de tráfico de drogas que negou cometer." (fl. 11)

Em Juízo, o acusado João Guilherme negou as acusações que lhe são imputadas. Negou ter vendido drogas na companhia do adolescente Luis Paulo, dizendo que o conhece apenas de vista. Confirmou a propriedade do entorpecente apreendido em seu poder e no telhado de sua casa, mas alegou que se destinava a seu consumo pessoal. Negou a existência do dinheiro. Respondeu que trazia consigo maconha porque havia acabado de adquiri-la em Catanduva e, nesse ponto, negou que tivesse em sua posse dois eppendorfs de cocaína. Confirmou que foi condenado em outro processo por crime de tráfico de drogas e quanto a outros fatos, apurados em outro processo, reconheceu que guardava drogas no telhado, alegando, mais uma vez, que se destinava ao seu consumo pessoal.

Essas são as provas.

Pois bem. Diante do que foi dito em audiência e juntado aos autos, está mais que comprovado que o acusado João Guilherme trazia consigo e guardava drogas para fins de tráfico, estando seguramente caracterizado o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Por outro lado, não restou suficientemente demonstrado que o acusado João Guilherme estaria associado ao adolescente Luis Paulo para o comércio ilícito de drogas, devendo ser absolvido no tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei nº 11.343/06).

Com relação ao crime de tráfico de drogas, as provas apontam, indene de dúvidas, que o acusado trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico. Com efeito, os policiais, em depoimentos coesos e livres de contradição, prestados tanto na fase policial como em Juízo, afirmaram a apreensão, na posse do acusado, de dois eppendorfs de cocaína e seis porções de maconha, além de certa quantia em dinheiro e um aparelho celular, bem como que ele guardava, escondido no telhado, outros 38 eppendorfs de cocaína, na forma de crack.

O próprio réu admite a propriedade do entorpecente e as circunstâncias da apreensão. Com a ressalva, apresentada apenas em juízo, de que trazia consigo apenas as porções de maconha, mas não os dois eppendorfs de cocaína.

Entretanto, ressalto que o depoimento dos policiais merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois inexistente qualquer indício de que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelo crime em apuração. Seus depoimentos foram seguros e coesos e merecem toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes – Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso.

Não haveria razões (que, aliás, não foram suscitadas tampouco demonstradas pela Defesa) para que os policiais forjassem a apreensão de parte inexpressiva da droga (dois eppendorfs de cocaína), conforme insinua o acusado. Lado outro, vê-se de outro processo a que respondeu neste Juízo, também pela prática do crime de tráfico de drogas, que é prática recorrente do acusado suscitar dúvidas sobre a ação policial, sem qualquer lastro probatório.

No mais, a alegação do réu de que o entorpecente apreendido destinava-se a seu consumo pessoal encontra-se refutada pelos elementos dos autos. Com efeito, as circunstâncias da apreensão, em especial a quantidade (número de porções individuais), diversidade (cocaína, cocaína na forma de crack e maconha), fracionamento e forma de acondicionamento das drogas, bem como o local em que guardada grande parte do entorpecente (no telhado), revelam sobremodo que se destinavam ao comércio ilícito a terceiros. Some-se a isso a apreensão de certa quantia em dinheiro, em espécie, cuja origem lícita não foi demonstrada, anotando-se que o réu nem mesmo comprovou o exercício de atividade profissional lícita.

Vale registrar, igualmente, que o réu responde a outros dois processos criminais por delitos de tráfico de drogas, sendo em um deles condenado em primeira instância, aguardando presentemente o julgamento de recurso interposto pela Defesa (1500090-92.2020.8.26.0531). Ressalto, ainda, a semelhança na maneira de agir entre os fatos apurados neste feito e nos autos da Ação Penal nº 1500247-47.2021.8.26.0558, na qual consta que o denunciado guardava, dentro do telhado, 33 (trinta e três) microtubos plásticos, do tipo eppendorf, contendo cocaína.

Destaque-se, enfim, que a simples condição de usuário não exclui a de traficante. Ao contrário, a experiência tem demonstrado que, em grande parte, usuários comercializam drogas também para o sustento do próprio vício, o que, entretanto, não exclui a tipicidade da conduta. Com efeito, no caso em apreço, o número de porções individuais apreendidas e sua variedade não se revela compatível com a tese de posse para uso pessoal.

Não por outra razão que dispõe o §2º do art. 28 da Lei de Drogas que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

De toda sorte, está evidente que o acusado busca, a qualquer custo, esquivar-se das consequências penais do crime a ele imputado.

Nesse cenário, há provas suficientes e seguras para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), na modalidade “trazer consigo” e “guardar”.

Com relação ao núcleo do tipo “vender”, igualmente atribuído ao réu na denúncia, não restou demonstrada a participação do acusado na venda realizada pelo adolescente Luis Paulo à testemunha Silvia. O que, no caso em apreço, revela-se indiferente, pois para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se faz necessário que o agente seja flagrado em ato de comercialização (venda) da droga.

Isto porque, o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure e, no mais, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo, em regra, por um só delito.

Em contrapartida, com relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) impõe-se a absolvição do réu. Não há provas idôneas de que João Guilherme estaria associado ao adolescente Luis Paulo para o comércio ilícito de drogas.

Os elementos de informação coletados durante o procedimento investigatório não foram confirmados em juízo. Nesse sentido, a testemunha Silvia afirma que as drogas com ela apreendidas foram adquiridas do menor Luis Paulo e que no momento da venda ele estava sozinho. Afirmou, também, nunca ter adquirido drogas do acusado João Guilherme, alegando sequer conhecê-lo, e negou ter dito na fase policial que Luis Paulo comercializava drogas associado ao acusado João Guilherme.

Por sua vez, o policial civil José Renato, que presenciou a venda feita por Luis Paulo à Silvia, ressaltou que o adolescente estava sozinho naquele momento e, no mais, de seu relato extrai-se que a venda não ocorreu na casa do réu João Guilherme, nem sequer na frente do imóvel, mas em local próximo (virando a esquina, a uns dez metros), o que não é suficiente a indicar eventual associação entre eles.

Já o policial civil Silvio Riva tampouco presenciou a citada comercialização.

E não há outros elementos de prova a indicar que os réus estariam associados, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Os policiais ouvidos em juízo nem mesmo apresentaram informações precisas a esse respeito. De outro lado, não se mostra suficiente à prova da suposta associação, eventual concurso do acusado e do adolescente na prática de crime de roubo. Aliás, vale citar que o deferimento da ordem de busca e apreensão na residência do réu deu-se em investigação por crime de roubo, dos quais João Guilherme e Luis Paulo são suspeitos, não tendo qualquer relação, a princípio, ao comércio ilícito de entorpecentes (fls. 60/61).

Nesse sentido, a propósito, o parecer final do Ministério Público.

Em vias de arrematação, o acusado, apesar de primário, não faz jus ao privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em face da constatação de que se dedica a atividades criminosas. Com efeito, o réu responde a outros dois processos de tráfico de drogas (1500090-92.2020.8.26.0531 e 1500247-47.2021.8.26.0558), por fatos ocorridos respectivamente em 25/02/2020 e 02/06/2021, sendo que, no primeiro deles, foi condenado em primeira instância, aguardando-se, presentemente, o julgamento de recurso defensivo (fls. 219/220). Além disso, há notícia de que o réu estaria sendo investigado pela prática de crime de roubo.

Nesse sentido a jurisprudência da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSOS EM ANDAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. A jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, é no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

Precedentes. 3. O fato do envolvido responder a processos criminais, ainda que não configure reincidência ou Maus Antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. 4. No caso concreto, as instâncias de origem concluíram pela dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando não apenas a existência de ação penal em curso, mas também a quantidade da droga apreendida (452 trouxinhas

de cocaína), a forma como estavam acondicionadas, além da apreensão de petrechos para a produção das substâncias ilícitas. 5. Ademais, mesmo que assim não fosse, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1932460/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

E pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante:

Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico – Apreensão de cocaína – Insurgência das partes – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o par. 3º, do art. 33, da LA – Não cabimento – Pedido ministerial para a condenação dos acusados, nos moldes do art. 35 da LA – Não comprovação de vínculo de permanência e estabilidade para a prática do narcotráfico. (...) – Terceira fase – Redutor não aplicado. Agiu acertadamente o nobre julgador, pois à época dos fatos, o acusado estava sendo processado criminalmente (Processo nº 0002118-79.2018.8.26.0272 - fls. 116/118 - tendo inclusive sido preso em flagrante por tráfico), o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação a atividade criminosa, segundo entendimento desta Relatoria. Importante acrescentar que em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que nos autos supramencionados, o réu foi condenado às penas de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 388 dias-multa, no mínimo legal - com trânsito em julgado para a defesa em 17/12/2020, que foi certificado aos 16/04/2021 (fls. 576 dos autos) -, o que reforça a não concessão da benesse, já que agora o réu ostenta maus antecedentes – Regime fechado mantido. Réu Isaac: Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em razão da quantidade-natureza da droga apreendida. Ainda que o entorpecente apreendido tenha alto poder viciante, verifica-se que a quantidade total (35,64 gramas de cocaína) não se mostra expressiva a ponto de justificar o aumento – Fixação no mínimo legal – Segunda fase – Presença da atenuante de menoridade relativa, porém sem reflexos na pena (Súmula 231, STJ) – Terceira fase – Redutor não aplicado – Embora o réu seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas (Processos nº 00003369-51.2020.8.26.0015, nº 0003359-54.2019.8.26.0272 e nº 0003360-39.2019.8.26.0272, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa – fls. 52), o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação a atividade criminosa – (...). Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP; Apelação Criminal 1501050-49.2020.8.26.0272; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 06/06/2022)

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu, inexistindo espaço para desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 2. Não incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. Processo em curso por tráfico de drogas pode ser considerado como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1524788-29.2019.8.26.0037; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Por fim, fixada a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nesse ponto, assevero que não é caso de majoração da pena nesta fase, como pretende o Parquet. A quantidade apreendida (em massa líquida) não se revela expressiva e a diversidade, no presente caso, não justificaria o aumento. Por outro lado, o réu não possui maus antecedentes e com relação à conduta social e personalidade do agente, ressalto que a existência de processos em curso por crimes de tráfico de drogas revelam dedicação à atividade criminosa, fator a ser considerado em terceira fase para fins de afastamento do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que não será sopesado neste momento, sob pena de bis in idem. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que a pena resta inalterada nesta fase.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento. Por outro lado, conforme já fundamentado (dedicação à atividade criminosa), inaplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Assim, torno a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos e não superior a 8 anos), a primariedade do acusado e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal.

E considerando a quantidade de pena (superior a 4 anos), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento.

Impossível, igualmente, a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, CP).

Por fim, ausentes os elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e assim o faço para CONDENAR o réu JOÃO GUILHERME DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Também o faço para ABSOLVER o acusado JOÃO GUILHERME DOS SANTOS da outra imputação que lhe foi irrogada na denúncia (art. 35, Lei nº 11.343/2006), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em observância ao art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, persistem os motivos cautelares (ordem pública – evitar reiteração criminal em face da dedicação à atividade criminosa) que fundamentaram a prisão, não havendo que se falar em revogação da prisão processual.

Contudo, uma vez que o réu foi condenado em regime semiaberto, o cumprimento da prisão cautelar deverá ser realizado em localidade idêntica ao regime ao qual foi condenado. Nesses termos, decisão do Superior Tribunal de Justiça: "ainda que se considere haver elementos suficientes para a negativa do direito de recorrer em liberdade, é certo que, tendo sido fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena reclusiva, configura constrangimento ilegal manter o apenado submetido a regime fechado. Não se mostrando razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que àquele que foi estabelecido na sentença condenatória. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente sua imediata colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação". (STJ. 6ª Turma. HC269.288/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/08/2013).

Oficie-se à Secretária de Administração Penitenciária para assegurar ao réu sua

imediate colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo encontrar-se em prisão em regime fechado. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Restando evidente o nexo etiológico entre o numerário constrito nos autos (fls. 106) e a prática do tráfico, não tendo o réu logrado em demonstrar a origem lícita do dinheiro, com fundamento na inteligência do art. 91, II, "b", do Código Penal, decreto sua perda em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006.

Oficie-se à autoridade policial competente para que providencie, nos termos do art. 58, §1º, e art. 32, §1º, ambos da Lei nº 11.343/2006, a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não o tenha feito.

Por fim, condeno o sentenciado ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03). Após o trânsito em julgado:

- i) proceda-se na forma do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/2006 com relação a eventuais bens e valores declarados perdidos em favor da União;
- ii) intime-se o réu para o pagamento da multa, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal;
- iii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal;
- iv) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação dos réus;
- v) expeça-se guia de execução penal.

P.I.C.

Santa Adélia, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA